

予備独自問題 H29-25

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【見解】を前提とした場合、後記アからオまでの【記述】のうち、厳格な証明を要する事実として正しいものの個数は、後記1から6までのうちどれか。

【見 解】

刑罰権の存否及び範囲を定める事実については、証拠能力があり、かつ、適式の証拠調べを経た証拠による証明（厳格な証明）を要する。

【記 述】

ア. 共謀共同正犯における共謀の事実

イ. 累犯加重となる前科

ウ. 暴行事件において、被告人が争っていない暴行事実

エ. 勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実

オ. 事後強盗事件において、被告人に逮捕を免れる目的があった事実

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No219	厳格な証明	正答率
予備H29-25	正解 5	47%

本問では、アからオまでの【記述】が、【見解】にいう「刑罰権の存否及び範囲を定める事実」に該当するか問題となる。これに当たるものとしては、①公訴事実（犯罪事実）、すなわち特定の犯罪構成要件に該当し違法かつ有責な具体的事実（処罰条件を必要とする犯罪類型（刑法197条2項など）の場合はこれを含む）、及び、②刑の加重減免の理由となる事実（再犯加重（刑法56条、57条）、自首減軽（刑法42条）など）が挙げられる。また、罪数判断に関係し、刑の決定に影響する事実についても同様に考えてよいとされている。

ア 厳格な証明を要する事実である

共謀共同正犯（刑法60条）における共謀の事実、公訴事実（犯罪事実）すなわち特定の犯罪構成要件に該当し違法かつ有責な具体的事実に属する事実であるから、「刑罰権の存否及び範囲を定める事実」に該当する。

判例（最大判昭33.5.28、百選A44事件）も、「『共謀』……は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない」としている。

イ 厳格な証明を要する事実である

累犯加重となる前科（刑法56条、57条）は、刑の加重減免の理由となる事実であるから、「刑罰権の存否及び範囲を定める事実」に該当する。

判例（最大決昭33.2.26、百選A31事件）も、「累犯加重の理由となる前科は、刑訴335条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実、刑の法定加重の理由となる事実であつて、実質において犯罪構成事実に準ずるものであるから、これを認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴305条による取調をなすことを要するものと解すべきである」としている。

ウ 厳格な証明を要する事実である

暴行事件における暴行の事実、暴行罪（刑法208条）の公訴事実（犯罪事実）すなわち特定の犯罪構成要件に該当し違法かつ有責な具体的事実に属する事実であるから、「刑罰権の存否及び範囲を定める事実」に該当する。

エ 厳格な証明を要する事実でない

勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実（60条1項1号）は、訴訟法上の事実に至らず、「刑罰権の存否及び範囲を定める事実」に該当しない。

オ 厳格な証明を要する事実である

事後強盗事件における逮捕を免れる目的があったという事実は、事後強盗罪（刑法238条）の公訴事実（犯罪事実）すなわち特定の犯罪構成要件に該当し違法かつ有責な具体的事実に属する事実であるから、「刑罰権の存否及び範囲を定める事実」に該当する。

以上により、厳密な証明を要する事実として正しいものはア、イ、ウ、オの4個であり、正解は肢5となる。